

1522320-33.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria.

Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Apenas, observo que, a despeito do local em que guardada a droga, a casa em que o acusado residia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1522320-33.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522320-33.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250741/2021 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 20248473 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 205/21/210 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 2250741 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERYCLES CHRYSTIAN DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

ERYCLES CHRYSTIAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 16 horas, na Rua Bartolome Ordóñez, nº 52, na última casa do quintal, nesta Capital, guardava e tinha em depósito, para o fim de tráfico ilícito de drogas, 542 (quinhentos e quarenta e duas) porções de maconha, com peso líquido de 2450 gramas; 805

(oitocentos e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 455,2 gramas; 475 (quatrocentos e setenta e cinco) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 156 gramas; e 70 (setenta) frascos em vidro contendo lança-perfume, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, o acusado guardava os entorpecentes em duas mochilas, que ficavam escondidas na casa, local dos fatos.

Narra a denúncia que policiais civis receberam denúncia anônima e foram até o imóvel para apurar venda, guarda e consumo de entorpecentes. No local, notaram forte odor de maconha. O acusado estava acompanhado da namorada que atendeu os policiais, franqueando-lhes o ingresso no imóvel. Ao realizar revista no local, eles encontraram as mochilas dentro de um cesto de roupas sujas. As drogas estavam nas mochilas. Além disso, encontraram um caderno tipo universitário, contendo apontamentos do tráfico.

Consta, ainda, da denúncia, que o delito foi praticado próximo a estabelecimento de ensino, uma escola estadual.

O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise da sua regularidade formal, o flagrante foi convertido em preventiva, às fls. 57-61.

Regularmente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar, às fls. 125-130, por meio da Defensoria Pública do Estado.

A denúncia foi recebida, às fls. 136-137.

Durante a instrução processual, foi colhido o relato da testemunha Hemily de Souza Bueno, ouvida como informante do Juízo, por se tratar de companheira do acusado), assim como das testemunhas Policiais Civis Marcos Fernando Pacheco e Sidnei Davi da Conceição.

Por último, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se debates finais em audiência.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado. Diante do volume de drogas apreendidas, pediu a fixação do regime fechado.

A Defensoria Pública, de seu lado, pediu a absolvição do acusado por falta de provas, assinalando a relatividade da confissão, bem como a precariedade dos depoimentos dos policiais civis, que possuíam algum interesse em legitimar suas ações e o resultado que alcançaram nas investigações, sendo que tudo teve início com denúncia anônima que sequer foi formalizada pela polícia. Não houve apreensão de dinheiro e os policiais sequer viram movimentação própria de tráfico. Pede o afastamento da majorante descrita na denúncia. Postula o reconhecimento da confissão para fins de abrandamento da pena e a aplicação do fator redutor da pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ou o redutor do artigo 41 da mesma lei. Requer, por fim, a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da cuidadosa análise do processado, verifica-se a procedência parcial do pedido, porquanto comprovada a materialidade e autoria delitiva, da prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com acerto, a materialidade do crime está devidamente comprovada, sobretudo a partir do Auto de Prisão em Flagrante e do Boletim de Ocorrência (fls. 01 e 15-18), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19-20), do Laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 82-85), tudo acrescido da prova oral colhida durante a instrução processual em Juízo.

A autoria, de seu lado, também resulta comprovada, acima de tudo diante do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, tudo acrescido da confissão do acusado, ao ser interrogado em audiência.

De início, impende anotar que o acusado reconheceu os fatos da denúncia. Esclareceu que estava com sua companheira em sua casa quando a polícia foi até o local.

Atendeu os policiais e franqueou o acesso deles ao interior do imóvel, mostrando o

local em que estava guardada a droga. Afirma que a droga não lhe pertencia. Que apenas guardava a droga para terceira pessoa, um agiota, para quem devia dinheiro. Estava com dificuldade de pagar o débito. Com seu trabalho, apenas conseguia pagar juros. Em certo momento, o agiota pediu que guardasse a droga durante algo entre quinze dias e um mês para quitar a dívida. Estava temeroso por sua vida e de sua companheira, pois o agiota fazia ameaças constantes de matá-lo e de matar sua companheira.

Segue que sua companheira, Hemilly de Souza Bueno, ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos, inclusive a posse da droga. No dia dos fatos, estavam em casa quando os policiais bateram a sua porta. Atenderam e admitiram o ingresso dos policiais. A depoente não sabia que ERYCLES guardava aquela droga em casa. Os policiais indagaram sobre a droga e ERYCLES prontamente apresentou tudo quanto apreendido.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Policial Civil Marcos Fernando Pacheco, após confirmar que a pessoa que estava em audiência era ERYCLES, relatou terem recebido denúncia anônima apontando realização de tráfico, com descrição da casa e do agente. Foram até o local. Tratava-se de uma residência com várias casas de aluguel. Segundo a denúncia anônima, tratava-se da última casa. Ao chegarem na casa, os policiais foram atendidos por ERYCLES, que lhes franqueou o acesso ao interior do imóvel. Encontraram a droga em um cesto de roupa suja. Havia cocaína, maconha, crack e lança perfume, tudo em uma mochila, com várias porções. Ainda, encontraram um caderno com anotações de quantidades e endereço, tudo aparentemente relacionado ao tráfico. A companheira ou namorada do acusado estava junto. Apenas os dois estavam na casa.

No mesmo sentido o relato do Policial Civil Sidnei Davi da Conceição que, em suma, estava na companhia do policial Marcos, relatando tudo quanto acima apontado por Marcos. Reconheceu o acusado em audiência e contou terem recebido denúncia anônima na delegacia, falando de um imóvel no qual havia drogas, tratando-se da última casa de determinado quintal. Foram até o local. O imóvel conta com várias casas e foram até a última casa, conforme indicado na denúncia anônima. O acusado estava na casa, com a esposa ou namorada. Ele autorizou o ingresso dos policiais e mostrou aonde estava a droga, em um cesto. Ao que se recorda, havia bastante quantidade de maconha e crack e acha que tinha lança perfume. Havia também um caderno. O acusado disse que a droga era dele e de uma outra pessoa. Estava guardando a droga. Conforme observado, a guarda da droga apreendida é inconteste, contando com a confissão do acusado, confirmada pela sua companheira, HEMILY, tudo em compasso com o quanto narrado pelos dois policiais civis que diligenciaram ao local, efetuando a apreensão do entorpecente e prendendo o acusado em flagrante delito, a determinar, de modo inexorável, o efetivo reconhecimento da autoria delitiva e da procedência parcial do pedido inicial..

Pois bem, sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, 8ª edição, Editora Atlas, pág. 469, assinala que "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos

testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Demais disto, a testemunha HEMILY, companheira do acusado, confirma tudo quanto narrado na denúncia, além do acusado ter confessado em juízo a guarda do entorpecente.

Estão presentes importantes evidências que apontam a narcotraficância, tais como: a) a natureza e a variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína, crack e lança perfume); b) a significativa quantidade de droga apreendida, incompatível com a condição de mero usuário (542 (quinhentos e quarenta e duas) porções de maconha, com peso líquido de 2450 gramas; 805 (oitocentos e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 455,2 gramas; 475 (quatrocentos e setenta e cinco) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 156 gramas; e 70 (setenta) frascos em vidro contendo lança-perfume); c) a forma de acondicionamento da droga apreendida; d) apreensão de caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico. Todos esses fatores são indicativos do destino das drogas para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu guardava e tinha em depósito as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Apenas, observo que, a despeito do local em que guardada a droga, a casa em que o acusado residia, estar posicionada próximo a uma escola estadual, não há nenhum laivo indicativo de que tenha havido qualquer aproveitamento deste fato na prática do narcotráfico pelo acusado.

A partir dos elementos de prova, fica evidenciado (ou ao menos não há nada em sentido contrário) que a guarda do entorpecente apenas circunstancialmente ficava em local próximo de escola, mas não se pode admitir a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porquanto a objetividade jurídica que lhe é própria não tenha sido ferida, de modo nenhum (como assinalado, ao menos não há nenhuma prova neste sentido).

A perspectiva desta norma é a de reprimir de modo mais severo a prática do narcotráfico se aproveitando o agente do fato de estar próximo a estabelecimentos de ensino, a determinar maior desvalor da conduta de oferecer ou viabilizar a entrega de entorpecentes a estudantes, sobretudo menores de idade. Não é esta a situação do acusado, não constando que tenha havido qualquer venda ou oferta de drogas na região. Apenas, o entorpecente estava guardado na casa do acusado, que fica próximo à escola. Não houve demonstração de nenhum ato de venda naquele local, não se revelando como possível a condenação com incidência desta majorante da pena, que fica, pois, afastada.

Por último, reputo inviável a aplicação da causa de aumento da pena definida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi flagrado guardando entorpecentes em sua casa. Não estava propriamente comercializando a droga, não consta que estivesse realizando venda de entorpecentes a terceiros. É certo que mantinha a droga guardada em seu poder para venda a terceiros, para fins de narcotráfico, mas não estava na prática da conduta de vender.

É certo que o local de sua morada, em que a droga estava, é próximo de escola, mas a finalidade da norma é a de punir o aproveitamento da situação de proximidade com a escola, além de tanger de maneira mais intensa a conduta de venda de drogas com amplo potencial de implicar estudantes, menores de idade ou jovens adultos, havendo a compreensão por parte deste juízo de que não há por parte da norma legal a

expectativa de punir mais severamente, com a incidência desta causa de aumento da pena, apenas por um fator meramente geográfico.

Aqui, em suma, não houve o aproveitamento da situação de proximidade com a escola ou a efetiva realização de venda a terceiros próximo da escola. Apenas acidentalmente o local de guarda do entorpecente dista poucos metros de uma escola, mas de per si esta situação não se revela como apta a desencadear a incidência da majorante da pena.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, verifico que, a despeito da primariedade do agente, a causa vertente compreende a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, a superar os três quilogramas totais de drogas, especificamente, 542 (quinhentos e quarenta e duas) porções de maconha, com peso líquido de 2450 gramas; 805 (oitocentos e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 455,2 gramas; 475 (quatrocentos e setenta e cinco) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 156 gramas; e 70 (setenta) frascos em vidro contendo lança-perfume). A quantidade e variedade das drogas são determinantes da maior reprovabilidade da conduta nesta primeira etapa de fixação da pena, a exigir resposta mais firme da Justiça Criminal.

Destaque-se que se está a seguir orientação consistente firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271).

Dessa forma, fica a pena-base estabelecida acima de mínimo legal, em uma quarta parte, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para o patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Registre-se que as circunstâncias atenuantes não podem determinar redução da pena para aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

À míngua de qualquer outro fator apto a alterar a pena aplicada, fica consolidada como definitiva aquela acima fixada, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme acima assinalado, diante da grande quantidade de droga apreendida e da sua variedade, não se perfaz como possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, o que determina a percepção da ligação sólida do acusado com o crime.

Nesse sentido, colha-se ementa do seguinte julgado:

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Versão do acusado sobre os fatos francamente inverossímil. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas nucleares. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Pena e regime mantidos. A diversidade e a quantidade dos tóxicos, bem como a localização de expressivo valor em dinheiro e contabilidade do tráfico, demonstram não se tratar o apelante da figura beneficiada pelo art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. A perda dos bens envolvidos na prática do tráfico é consequência "ex lege". Recurso improvido" (Apelação Criminal n.º 1507951-68.2020.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator Des. Francisco Bruno. Data do julgamento: 13/05/2021. Data de publicação: 18/05/2021) – grifos nossos.

Do regime de cumprimento de pena:

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo aplicando-se a detração, considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, verifico que não há como fixar, no presente caso, regime diverso do inicial fechado para

reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se a considerável quantidade, variedade e natureza da droga que o réu guardava e tinha em depósito, a denotar que não se tratava de modesto tráfico. Pelas mesmas razões e também em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos se mostra inviável, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 e seguintes do Código Penal, pois as circunstâncias do delito indicam que essa substituição não é suficiente à reprovação e prevenção do crime equiparado a hediondo que vem se alastrando.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ERYCLES CHRYSYIAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

O acusado vem respondendo aos termos do processo cautelarmente preso e assim deve permanecer. Com acerto, até aqui a percepção do Juízo foi da necessidade de manutenção da custódia cautelar, não havendo nenhum fato novo que justifique qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade. Fica, pois, vedada a possibilidade de recorrer em liberdade.

Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do disposto no Provimento CG 04/2020 e 05/2022, elabore-se cálculo de multa e expeça-se certidão da sentença. Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público para eventual ajuizamento de processo de execução da pena de multa.

Efetivada a transação ou efetuado o pagamento, comunique-se ao MM. Juízo das Execuções Criminais competente.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA